

1518759-64.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Eduardo Pereira Santos Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/10/2022

... da aludida folha de papel com a contabilidade do tráfico, mencionada pelo PM Diógenes, o que seria imprescindível, no caso, sobretudo frente as lacunas deixadas nos depoimentos prestados.

Roberto, de sua parte, negou de forma veemente a prática do tráfico. Estava no local somente para adquirir entorpecentes do adolescente, o verdadeiro traficante.

Demais disso, na ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

5ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraao Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518759-64.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518759-64.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2227696/2022 - 56º D.P. VILA ALPINA, 26883725 - 56º D.P.

VILA ALPINA, 2227696 - 56º D.P. VILA ALPINA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MACIEL DIAS DA SILVA e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Eduardo Pereira Santos Junior

Vistos.

ROBERTO GARCIA HYPOLITO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inc. VI, ambos da Lei 11.343/2006, c.c. artigo 61, II, 'j', do Código Penal porque, no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 6 horas e 20 minutos, na Rua José de Castro Lima Filho, altura do nº 200, São Lucas, nesta cidade e comarca da capital, previamente ajustado e com unidade de desígnios com o corréu MACIEL DIAS DA SILVA (processo suspenso nos termos do art. 366 do CPP) e o adolescente Lukas Espedito Andrade Vale, traziam consigo e guardavam, para fins de tráfico, 78,4 gramas de maconha e 33,9 gramas de cocaína, substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls. 131/132).

Recebida a denúncia (fls. 150 e 151), foi o réu citado (em audiência). Apresentou resposta à acusação (em audiência). O corréu Maciel foi citado por edital e o feito foi suspenso nos termos do art. 366 do CPP (fls. 209/210). Afastada a hipótese de absolvição sumária, procedeu-se à instrução criminal, com a oitiva de duas testemunhas arroladas na denúncia e interrogatório ao final.

Em debates, o Ministério Público postulou a condenação nos termos da denúncia.

A Defensoria Pública requereu a absolvição por insuficiências de provas. Subsidiariamente, pleiteou o afastamento da causa de aumento de pena articulada.

É o relatório.
DECIDO.

A materialidade restou comprovada por autos de apreensão e constatação (fls. 26/27 e 21/25) e laudo de exame químico-toxicológico (fls. 187/189).

O réu permaneceu calado na fase policial (fls. 9).

Em juízo, Roberto negou a prática do tráfico de drogas. Declarou ser usuário de crack e cocaína. Na data do fato, após discussão com sua esposa, saiu de casa e teve uma recaída. Por volta de 6 horas da manhã resolveu comprar crack. Havia outro usuário no local, chamado Gabriel. Aguardava o traficante quando a polícia chegou, já trazendo outro rapaz, o olheiro. O traficante, que era menor de idade, fugiu. Nunca havia visto os policiais antes.

O policial militar Gabriel Augusto Martines do Nascimento declarou que já havia abordado Roberto no dia anterior, mas nada foi apreendido em seu poder. Na data do fato, percebeu uma movimentação suspeita no interior da comunidade. Viu Roberto entregando uma bolsinha ao menor, que correu. Roberto inicialmente declarou ser usuário, tal como alegara no dia anterior. Seu parceiro conseguiu alcançar o menor de idade e com ele localizou a bolsa com as drogas. Havia maconha e algumas drogas químicas, além de dinheiro. Com o réu nada foi encontrado. Durante a abordagem, o acusado acabou por confessar que estava traficando há alguns dias. O adolescente confirmou que na noite anterior havia fugido da viatura. O corréu Maciel admitiu ser olheiro.

O policial militar Diógenes Fernando Batista Antunes disse ter efetuado incursão em comunidade conhecida pelo tráfico de drogas. Seu parceiro desembarcou da viatura. Logo na sequência avistou o adolescente correndo e o deteve. Ele trazia consigo dinheiro trocado na jaqueta e uma bolsa com as drogas. Havia cocaína, maconha, skunk e alguns anotações com o nome "Beto". Na anotação havia a quantidade de droga recebida por "Beto" para vender à noite. Seu parceiro viu o réu Roberto entregando a bolsa ao adolescente. O adolescente, por sua vez, alegou que atuava sozinho e ainda ofereceu dinheiro para se livrar do flagrante. Já havia abordado o corréu Maciel em outra ocasião, se tratando de usuário de drogas que atua como olheiro. O réu Roberto alegou inicialmente que era usuário, mas acabou por confessar que

atuava no tráfico há pouco tempo, como olheiro. Maciel tinha aparência de usuário, mas Roberto não. Nada de ilícito foi apreendido em poder dos réus.

A prova produzida sob o crivo do contraditório é insuficiente à condenação.

Deveras, em juízo, não sobreveio evidência hábil a firmar a responsabilidade de Roberto.

Em poder do réu nada foi apreendido. Contra ele, restou apenas o inconsistente depoimento do PM Gabriel, que disse ter presenciado, à distância, a entrega de uma bolsa com drogas ao adolescente Lukas. Porém, o policial Gabriel não soube esclarecer as condutas dos demais agentes envolvidos na ocorrência, que é recente, vale registrar. Foram quatro os agentes detidos: os réus Roberto e Maciel, um adolescente e um usuário de drogas.

Não consta dos autos, ademais, a notícia da apreensão da aludida folha de papel com a contabilidade do tráfico, mencionada pelo PM Diógenes, o que seria imprescindível, no caso, sobretudo frente as lacunas deixadas nos depoimentos prestados.

Roberto, de sua parte, negou de forma veemente a prática do tráfico. Estava no local somente para adquirir entorpecentes do adolescente, o verdadeiro traficante.

Demais disso, na fase policial, o usuário Gabriel corroborou a alegação de que o responsável pela venda das drogas era o menor de idade (fls. 7). O próprio adolescente, também na fase policial, confessou o tráfico de drogas. Acrescentou que o papel do réu era atuar como “olheiro”, ou seja, na função de alertar os comerciantes de drogas sobre a chegada da polícia (fls. 8).

Restaram indícios, assim, quando muito, de que Roberto atuava como “olheiro”, sem efetuar diretamente a venda das substâncias.

Nesse contexto, poderia estar provado o crime do artigo 37 da Lei de Drogas.

Ocorre, porém, de acordo com o que estabelece o princípio da correlação, a sentença deve guardar correspondência direta e imediata com a denúncia. O réu defende-se dos fatos articulados na inicial acusatória. E, no caso em exame, não se cuidou de imputar a Roberto prática do crime do artigo 37 da Lei 11.343/2006, que não se encontra descrito na denúncia. Assim, só resta mesmo a absolvição, sob pena de ofensa ao princípio da congruência ou correlação.

Sobre o tema, confira-se trecho de v. Acórdão de relatoria do Eminentíssimo Desembargador Marcio Bártoli, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“O significado da regra do art. 383 do CPP é bem claro: permite-se somente a simples correção da capitulação legal da conduta, sem interferência na exposição do fato criminoso e suas circunstâncias. A descrição fática continua a mesma, nos termos da lição de Fernando Tourinho Filho: “Se a peça acusatória descrever o fato criminoso perfeitamente, mesmo tendo havido uma errada classificação da infração, não será obstáculo a que se profira sentença condenatória. Afinal de contas, o réu não se defende da capitulação do fato, e sim deste. Quando o réu é citado, dá-se-lhe conhecimento do fato que se lhe imputa. É desse fato que ele se defende. Assim, uma errada classificação da infração não pode constituir obstáculo à prolação de eventual sentença condenatória. Diz-se, até, que nessa hipótese nem haverá uma alteração do libelo, isto é, uma alteração da peça acusatória, mas, simplesmente, uma corrigenda (emendatio libelli). Aí, três hipóteses podem ocorrer: a) a pena não se altera; b) modifica-se para melhor; c) modifica-se para pior”. No mesmo passo, ensinam Grinover, Scarance e Magalhães: “de acordo com o art. 383, o juiz, ao

julgar a pretensão, deve dar ao fato imputado a correta qualificação jurídica, dizendo qual o direito aplicável ao caso concreto. A adequação feita pelo promotor de justiça ou querelante é meramente provisória; por sua vez, o réu se defende da imputação relativa a determinado fato descrito e não de sua capitulação jurídica. Assim, por exemplo, se o promotor de Justiça atribui a alguém a prática de furto porque, com um puxão subtraiu uma corrente de outro do pescoço da vítima, ferindo-a, nada impede ao juiz condenar o agente por roubo. A pena pode ser mais grave, sem necessidade de qualquer providência prévia, uma vez que não houve alteração do fato a respeito do qual foi exercido o direito de defesa. Outra situação existe quando o fato considerado pelo juiz, em face da prova, já não é o mesmo, ou seja, devido a uma circunstância elementar, não contida, explícita ou implicitamente, na denúncia ou na queixa, o fato é outro. Alguma particularidade altera-lhe a fisionomia, exigindo do juiz determinadas providências para a garantia ampla do direito de defesa. Com elas evita-se o julgamento além do pedido (...) Portanto, a fundamentação da sentença estava umbilicalmente ligada e limitada à descrição fática contida na denúncia, que imputava um crime de associação para o tráfico, e dela a decisão não poderia ter se afastado e condenado o agente por outro crime, mediante aplicação da regra do art. 383 destinada, exclusivamente, a meras correções. Portanto, nenhum réu pode ser acusado de um fato penal e condenado por outro, sem que o Órgão do Ministério Público adite a denúncia e sem a oitiva prévia do acusado, omissões que configuram ofensas à garantia do contraditório e que contaminam a sentença de nulidade substancial". (Apelação nº 0009604-07.2011.8.26.0161, Rel. Des. Márcio Bártoli).

Demais disso, ainda que se admitisse a falta de congruência entre a sentença e a denúncia, o caso continuaria a ser de absolvição, seja por falta de prova de vínculo do acusado com as drogas mencionadas na denúncia, ou de que a condição de olheiro se dava "como informante, com grupo, organização ou associação destinada à prática dos crimes previstos nos arts. 33 e parágrafo 1º e 34", como exige o tipo penal em exame.

Havendo fragilidade probatória, aplicam-se os princípios "in dubio pro reo" e "favor rei".

Posto isso, JULGA-SE IMPROCEDENTE a ação penal para absolver ROBERTO GARCIA HYPOLITO da infração ao artigo 33, "caput", do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Autorizo a incineração dos entorpecentes apreendidos, oficiando-se à autoridade policial.

Autorizo a destruição do objeto (pochete), oficiando-se.

Com o trânsito em julgado, comunique-se o IIRGD e a Justiça Eleitoral, lançando-se anotação sobre a condenação em sistema próprio (art. 372 das NSCGJ) e expedindo-se a guia de recolhimento definitiva.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados.

São Paulo, 06 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA